

1500429-04.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... que o acusado não faz jus à redutora inerente ao tráfico privilegiado, na medida em que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito da sua condição de primário aos olhos da lei penal.

Afinal, o réu, desempregado à época dos fatos, não logrou comprovar ao longo da instrução processual que exercesse qualquer atividade lícita ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500429-04.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500429-04.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122839/2022 - 02º D.P. LORENA, 24777627 - 02º D.P.

LORENA, 2122839 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

PABLO JONATAS DE JESUS CASTRO e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUIZ GUSTAVO DA SILVA MOTTA, PABLO JONATAS DE JESUS CASTRO e ULISSES ELIAS MARINHO, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 182/183).

Oferecida a denúncia, os réus apresentaram defesas prévias (fls. 192/205, Pablo; fls. 255/263, Luiz; e fls. 267/270, Ulisses). Em seguida, a denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 275/278).

No curso da instrução foram ouvidas testemunhas, e uma informante judicial. Na sequência, os réus foram interrogados.

A acusação apresentou alegações finais orais em audiência (mídia - fls. 336/337) e

as defesas, por memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A defesa do corréu Pablo, em preliminar, sustentou a nulidade das provas, alegando que estas foram produzidas com violação à garantia da inviolabilidade do domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou: o reconhecimento da atenuante da confissão; a aplicação da redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e o estabelecimento do regime inicial intermediário (fls. 339/349).

As defesas dos outros acusados manifestaram-se em sentido semelhante (fls. 350/360 e 366/369).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar invocada pelas defesas.

Compulsando as provas, verifico que a ação policial observou os limites da Constituição Federal.

Decerto, conforme se depreende dos depoimentos dos agentes públicos, a entrada deles no imóvel foi precedida por ação de indivíduo suspeito que, após ser visto com algo volumoso entre as mãos e por debaixo das vestes, saiu em fuga ao perceber que seria abordado por aqueles, lá ingressando.

Assim, nota-se que haviam razões objetivas para que os policiais militares suspeitassem da ocorrência de algo de ilícito no interior da residência, ante do cenário descortinado, o que justificava suas atuações.

Insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), estabeleceu diretrizes para o controle judicial em tais hipótese, firmando a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

A propósito:

“Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Preliminar – Ilícitude da prova obtida por suposta invasão de domicílio – Inocorrência – Nulidade processual não verificada – Incidência do redutor especial – Inviabilidade, diante das circunstâncias fáticas concretas apuradas, incompatíveis com a traficância ocasional – Apenamento reduzido pelo reconhecimento de equívoco aritmético, com correção também de erro material relacionado ao tipo penal em que incurso o recorrente – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500324-17.2019.8.26.0626; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 23/09/2021) (Sublinhado meu).

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 44/48), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 105/108), laudo de constatação provisória (fls. 69/72) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 169/171), com resultado positivo para "cocaína" e "tetrahidrocannabinol - maconha - THC", substâncias presentes na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa, à vista da confissão do trio de acusados.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o corréu Pablo revelou que, assim como Ulisses e Luiz, seus amigos, foi contratado para embalar as drogas apreendidas. Para tanto, cada um receberia quinhentos reais. Afirmou que em razão da dificuldade financeira que vivia à época, aceitou a oferta de um desconhecido, morador do seu bairro, que o abordou em via pública. Indagado, negou que tenha presenciado Luiz assumir a posse das drogas aos policiais militares. Informou que não viu ninguém entrando na casa, e que tentou fugir com Ulisses tão logo notou que os policiais militares tinham ingressado no imóvel, pulando para a casa vizinha. Por fim, disse que não havia outras pessoas na casa, além deles (acusados).

Postura semelhante adotou Luiz em sua autodefesa. Igualmente admitindo a aceitação da oferta de embalar os entorpecentes pelo valor de quinhentos reais, Luiz afirmou que assim agiu essa única vez. Questionado, esclareceu que no momento da abordagem assumiu a posse dos narcóticos, pois estava em sua casa, silenciando aos policiais sobre o valor que iria ganhar pela tarefa. Disse ter sido preso no mesmo dia em que recebeu as drogas, esclarecendo que estas estavam juntos com os apetrechos em uma bolsa, e que foram deixados pela mesma pessoa (contratante). O interrogando negou que houvesse uma quarta pessoa envolvida, que supostamente teria entrado correndo em sua residência. Afirmou que o portão da casa estava trancado. Ao final, contou que o dinheiro apreendido era de sua esposa e de seu filho, recebido de forma lícita pelo trabalho daquela.

O corréu Ulisses seguiu a mesma linha. Acrescentou dizendo que ninguém correu para o interior da residência de Luiz. Declarou que um conhecido ofereceu-lhe dinheiro para embalar as drogas, o levando até a casa do corréu Luiz, e que aceitou a tarefa, por dificuldades econômicas. Disse que mora praticamente em frente da casa deste e que, em regra, o portão fica fechado, porém, destrancado. Por fim, afirmou que apenas Pablo e ele pularam o muro, na tentativa de fugirem dos policiais.

Frise-se que a confissão dos réus está em linha com o relato das testemunhas de acusação. Senão vejamos.

O policial militar Rogério Gomes de Aquino declarou que durante patrulhamento de rotina surpreendeu um indivíduo carregando um objeto por debaixo das vestes, resolvendo abordá-lo. Contudo, este, ao perceber sua iminente abordagem, tentou fugir, entrou na residência apontada na denúncia. Diante da desconfiança gerada por tal atitude, a testemunha saiu ao seu encalço, notando que no interior do referido imóvel havia outras três pessoas, sendo que duas delas igualmente passaram a fugir, pulando para o quintal da residência fronteira àquela, enquanto a outra, como se apresentou como proprietário da casa, permaneceu inerte. De acordo com o depoente, os dois fugitivos que se encontravam na casa foram alcançados e abordados. Já aquele visto em via pública, não. Contou que no interior da residência foi apreendida grande quantidade de drogas e apetrechos comumente utilizados no vil comércio, além de dinheiro, e que o corréu Luiz confessou que havia comprado aquela droga para revende-la no varejo. Disse que não conhecia os réus até o dia dos fatos.

O policial militar Luiz Renato Bueno da Silva fez eco às suas palavras.

A irmã do corréu Ulisses, Samantha Helena Marinho contou que saiu para colocar o lixo na rua, vendo a bicicleta daquele encostada. Afirmou que, nesse momento, chegou uma viatura de polícia e, após parar em frente à casa de Luiz, os agentes públicos dela saíram e entraram imediatamente naquele imóvel, cujo portão encontrava-se aberto. Disse que, passado um tempo, os policiais saíram da casa dizendo que dois ou três pessoas haviam pulado para outra residência. Questionada, declarou que não viu ninguém correndo para o interior da casa de Luiz, além dos agentes públicos. Afirmou que seu irmão já teve envolvimento com o vil comércio. Indagada, disse que os três réus são amigos, e que Ulisses e Pablo frequentavam a casa de Luiz.

Já o casal Sônia Aparecida Silva Batista e Edson Luís Batista, vizinho do corré Luiz, contou que não presenciou os fatos em julgamento, mas que ninguém pulou para dentro de sua propriedade.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão dos réus se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelos increpados, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

“Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final”. (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Anote-se que a versão apresentada pelos réus de que ninguém teria corrido para o interior da casa de Luiz não se reveste de verossimilhança.

Com efeito, a despeito das afirmações da parcial informante e irmã de Ulisses, e das testemunhas de defesa Edson e Sônia, as quais afirmaram que ninguém pulou no quintal deles, como se viu acima, os próprios acusados admitiram que, ao menos, Ulisses e Pablo assim o fizeram, em linha com o relato dos policiais militares.

Ademais, convém registrar a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp

875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente?

Frise-se que os policiais militares e os réus não conheciam uns aos outros.

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, como o caso da irmã do réu Ulisses, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decísium o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados”. (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

No mais, destaco que apenas a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos é suficiente para configurar tal delito, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia, sendo a finalidade mercantil demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, não só pela própria confissão dos acusados, mas, também, pela quantidade e apetrechos apreendidos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, de rigor a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

a) LUIZ GUSTAVO DA SILVA MOTTA:

Conforme revela a certidão de fls. 303/306, além de reincidente, o réu ostenta maus antecedentes, por conta da condenação sofrida nos autos nº 1500449-50.2021.8.26.0323.

Ademais, cabe valorar negativamente nesta etapa, a vultuosa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. Afinal, trata-se de 7,16 gramas de “maconha”, e impressionantes 2.349,47 gramas, peso líquido, de “cocaína”; ou seja, mais de 02 (dois) quilos e 350 (trezentos e cinquenta) gramas, peso líquido, de drogas.

Portanto, à luz de tais circunstâncias, hei por bem fixar a pena-base em 3/8 (três oitavos) acima do piso legal, ou seja, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na fase intermediária, observo a incidência de duas circunstâncias preponderantes. De um lado, a atenuante da confissão; e de outro, a agravante da reincidência

(autos nº 0005758-39.2015.8.26.0323 - fls. 303/306). Logo, neutralizo seus efeitos, mantendo as penas inalteradas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 585 - Compensação - Possibilidade - Confissão - Reincidência, que passou a vigorar com a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Na terceira e última fase, considerando a inexistência de causas alteradoras da sanção, por isso, torno-as definitivas tal como fixadas na primeira fase.

b) PABLO JONATAS DE JESUS CASTRO:

O acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 300).

Contudo, valem aqui as mesmas considerações lançadas na dosimetria de Luiz Gustavo (quantidade e diversidade de drogas).

Portanto, mantendo-se a proporcionalidade, estabeleço as basilaes com elevação de 1/3 (um terço) do piso legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda etapa, por se tratar de réu confesso, reduzo as penas em 1/6 (um sexto), finalizando-as em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Insta salientar que o acusado não faz jus à redutora inerente ao tráfico privilegiado, na medida em que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito da sua condição de primário aos olhos da lei penal.

Afinal, o réu, desempregado à época dos fatos, não logrou comprovar ao longo da instrução processual que exercesse qualquer atividade lícita remunerada, ainda que eventualmente. Nem mesmo que o dia dos fatos tenha sido a primeira vez que tenha sido contratado para auxiliar no nefasto comércio, tal como tentou fazer crer em seu interrogatório.

Aliás, o próprio volume de drogas encontrado somado aos diversos apetrechos utilizados no vil comércio (duas balanças de precisão, pinos de plásticos do tipo eppendorf, facas e tesoura), indica justamente o contrário, a reforçar a conclusão acima exarada, ou seja, de que o acusado se dedicava à época às atividades criminosas.

Neste sentido, trago à colação, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o

agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado, não sendo o caso do acusado.



Registre-se que tal entendimento encontra-se em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas não foram os únicos elementos a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, conforme fundamentação supra, não se podendo cogitar no odioso e proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intollerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

c) ULISSES ELIAS MARINHO:

O réu é reincidente (fls. 301/302), razão pela qual tal circunstância será

considerada na etapa subsequente.

Todavia, valem aqui novamente as mesmas considerações com relação ao volume e natureza dos entorpecentes.

Assim, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na fase intermediária, observo a incidência de duas circunstâncias preponderantes. De um lado, a atenuante da confissão; e de outro, a agravante da reincidência (autos nº 1500505-67.2018.8.26.0621 - fls. 301). Logo, neutralizo seus efeitos, mantendo as penas inalteradas.

Na última etapa, não existindo outras causas modificadoras das penas, torno-as definitivas como estabelecidas na primeira fase.

O regime inicial de cumprimento será o fechado para todos, em vista das circunstâncias concretas acima expostas, reforçadas pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelas reincidências específicas de Luiz e Ulisses, com base no artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal.

Anote-se que o lapso temporal necessário para os fins da providência de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não foi atingido.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que não se dar cumprimento ao compromisso assumido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal, à vista do montante de pena privativa aplicada. De todo modo, tais medidas mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação da conduta, dada a hediondez do crime de tráfico, e o passado criminal comprometedor de Luiz e Ulisses.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

a) LUIZ GUSTAVO DA SILVA MOTTA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, uma pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, diária mínima;

b) PABLO JONATAS DE JESUS CASTRO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, diária mínima; e

c) ULISSES ELIAS MARINHO, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 06 (seis) anos e 08

(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade aos acusados. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam suas prisões preventivas se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Ademais, as penas relativamente altas que lhes foram impostas, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, conferem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Em reforço, convém apontar que os corréus Luiz Gustavo e Ulisses são reincidentes.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeçam-se as guias de execução provisória.

Custas pelos vencidos.

Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à autoridade policial para destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06, vez que a defesa não conseguiu provar que esse valor apreendido no contexto do vil comércio, tinha origem lícita, considerando que o documento de fls. 361 aponta valor recebido pela esposa do acusado Luiz muito próximo da quantia apreendida, ou seja, não é crível que eles guardariam, praticamente, todo o salário dela, em dinheiro trocado, em casa. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Preliminar - Restituição de valor apreendido - Desacolhimento - Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas - Inexistência de prova

segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Com relação aos celulares e tablet, igualmente apreendidos, como nada fora produzido nos autos indicando o emprego deles no crime destes autos, ou mesmo de que eram produtos do mesmo e de qualquer outro delito, intimem-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-los. Não sendo tais aparelhos reclamados, no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverão ser revertidos ao Funad; salvo se não apresentarem mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, ficam autorizadas a destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se os complementos das guias de execução; b) Intimem-se os acusados para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA